

# 自由权 最重要的基本权利

## 一、自由权概述

### 1. 人权的核心领域，最早的人权（第一代）

人的自由是人格实现的前提

### 2. 消极的权利（防御权）

防御公权力的侵害，公权力的保护义务 ex: 对民法的辐射

### 3. 范围与种类

(内在信仰, 外在表达)

三大自由权: **人身自由** **精神自由** **经济自由** (私有财产权) → 营业自由, 择业自由等

所有具体的自由权都可以归属于这三类自由权

自由权的核心要义: **自我决定**、**自我选择**、**自我承担责任**

## 二、人格权（人格自由）

### 1. 人格权的含义

人格: 人的存在

狭义——包括精神的、道德的层面 理性 (区别于动物的)

广义——除了上述“高尚”的层面以外，还包括物质的、生活的、生理的“庸俗”的层面 - **人的全面存在**

### 2. 人格权的保护领域

(1) 德国法上的“**一般行为自由**”

只要不影响公共秩序就行

人格的形成与塑造通过日常生活中的琐碎的、平常的行为而实现

例如: 穿衣打扮的自由、“放鹰行猎的权利”、“染发的自由”等

(2) 人格保护的**特殊领域**

. 私人领域、私密领域以及个人保密领域:

如卧室、私人日记，不想让他人知道的个人隐私

. 个人的**名誉**

. 关于自己记述的处分权 (档案制度)

. 个人**肖像**、特定语言的权利

. 免受被捏造地加以描述的权利

(3) **自我决定权**

关于个人生活中**重要事项、利益的选择判断权**，关涉到个人生活设计、重大选择事项

美国的“堕胎权”、“使用避孕工具”之**隐私权**

德国: 禁止使用测谎仪——“对于人类精神领域的有系统的侵入” **违反人“撒谎”的天性**

### 3. 中国宪法上的“人格尊严”

《宪法》第 38 条规定: “中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方式对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害”。**对世权**

缺乏宪法实践去充实和明确

保护范围不明，由于缺乏宪法实践和理论研究

参照民法理论: 一般人格权

具体人格尊严: 姓名、名誉、肖像、隐私和贞操 台湾

**人格权上的人格尊严**

## 三、人身自由

### 1. 个人具有保持身体活动、不受任意拘束的自由以及保持身体完整的自由

双重涵义（后者逐渐淡化）:

个人的身体活动不受国家的任意、非法拘束

不得以破坏个人身体完整的刑法制裁违法、犯罪者-反酷刑 制造肉体上的痛苦

## 2. 人身自由的界限

内在限制: 排除他人妨碍并不得妨碍他人的自由

不得违反宪法保障人身自由的目的 人格健康的发展

禁止以人的身体为标的的买卖、交易“卖身为奴”

## 3. 保障人身自由的宪法性原则或制度

(1) 法无明文不为罪、**罪刑法定** (现代刑法的基本原则)

法不得溯及既往、刑法上禁止类推

(2) 剥夺人身自由的决定应由**法院**作出

中国的劳教制度、收容审查、收容教育

(3) 剥夺人身自由的措施应由**法定机关**执行→**公安机关**

(4) 禁止以人身为买卖标的

## 4. 中国宪法上的保障人身自由的条款

宪法第37条: 中华人民共和国公民的**人身自由不受侵犯**。任何公民, 非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定, 并由公安机关执行, 不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由, 禁止非法搜查公民的身体。

## 四、居住和迁徙自由

### 1. 居住自由

住所自由: **个人居住处所不受国家任意干预**

国家工作人员未经法定程序不得进入私人住所

司法批准 法官签发搜查令

德国: 警察不得在“日落以后、日出以前”进入民宅, 除非发生水灾、火警或发生重大刑事案件

对住所的扩张解释: 宾馆也是住所

中国宪法上的规定: 第三十九条: 中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

也是对世权 可以适用于民法领域

### 2. 迁徙自由 (选择居住地)

(1) 内容: 选择居住地的自由

包括**国内迁徙自由**和**出国自由**

(2) 性质: 属于**经济自由**的范围

劳动力的流通是市场经济的必要条件

(3) 中国宪法

没有规定迁徙自由 但实际上人们享有一定的迁徙自由

当代中国迁徙自由的限制因素: **户籍制度** 城乡差距

历史原因: 农耕社会的生产方式, 把劳动力固定在土地上

未列举的权利 (但很容易推断得出)

## 五、工作自由

1. 内容: 选择职业的自由与经营自由 (**择业自由与营业自由**)

前者关系到**生存权**, 宪法着重予以保护, 后者属于**经济自由**的范围, 受到**公共利益**的制约

德国的药房案件: 对营业自由的限制是否适当

中国案例: 学校500米范围内不得开设游戏房; 具有刑事犯罪记录者不得从事出租车营运

中国宪法无工作自由条款 近似条款——**劳动权**条款:

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

### 2. 工作自由的限制问题

公权力对于私权利的“比例原则”  
判断政府行为是否合理合法

必要性原则 (合目的) 手段和目的正相关  
必要性原则 (最小侵害) 选择对公民权利限制最小  
均衡性原则 (狭义比例原则) 为成本与代价



ex: 上海禁止有前科的人开出租 → 不符合必要性

必须基于公共利益  
进行限制

国家专营制度——盐业、烟草、铁器（古代）酒业、军械等

“与民争利”？X 对择业自由的不当限制？

风俗行业的禁止——色情行业的合法化问题

国家对工作自由的正当限制——教师、律师、法官、医生等行业 **专业性** 关系重大公共利益

六、表达自由（外在的精神自由）

1. 含义：通过特定方式，将内在的精神、思想、情感等向外界表达的自由

2. 意义：人格发展与实现的必要条件，人类文化、文明传播的必要手段

3. 表达方式：言论、著作、新闻出版、游行、集会、示威等等。

4. 言论自由：

如希望国家改革

广告

宪法上的言论自由具有**表达自由和政治权利**的双重属性（与商业言论自由相对应）

宪法予以着重保障：人民参与政治过程、监督国家、人格形成与发展之功能

5. 著作自由：以**文字、图画**等方式表达的自由 **写书** 现代不怎么受重视，除非出版中国的“文字狱”

6. 新闻出版自由：**越发受重视**

出版：以**印刷、复制**的方式大规模发行

新闻：通过**现代传媒**发布、传播、报导

7. 集会、游行、示威自由 **多人聚集 破坏交通 影响广告**

静态  
动态

集会：多数人在**固定场所**表达思想、意愿等精神活动 **室内/室外集会**

游行：以**列队行进**的方式表达思想、意愿等精神活动 **对公共安全秩序影响大**

示威：以集会、游行等方式**显示力量 难以管理**

8. 管理体制：目的在于**保障**而**不在于限制** **对公共/他人利益产生冲突**

**事先干预** 许可制（我国对集会、游行、示威实行） **登记制** 事后追惩制 **登记制**

可能有损害自由

9. 中国宪法上的规定

**报备审查制**

**也是为公共安全 拟提前准备**

第三十五条：中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

10. 表达自由的界限与保护

(1) 禁止事先干预

许可制就是典型的事先干预

(2) **明确、即刻的危险** **才能去限制干预** 比如发生暴力行为。

(3) **较低限制手段**

**比例原则**：妥当性原则

**最小侵害原则**

**狭义比例原则**

**焚烧国旗案——表达自由**

新媒体时代表达自由的新问题

1. 表达自由的“敌人”不再仅仅是政府

资本对表达自由的干预和整肃

阿里巴巴蒋凡事件

2. 政府大范围的事先干预在技术上面面临困难 → **采用其他方式干预**

**自媒体的发达**

3. **信息泛滥**：错误信息、谣言

**公众辨识能力**

七、**结社自由** **中国对结社管理严格**

1. 涵义：个人组织、参加社会团体的自由

与集会相对应，前者是短暂的集合，而结社是基于某种目的长久的结合

2. 性质: 具有表达自由和行为自由的双重属性  
目的在于增强人民的互助、自卫能力, 增进交流机会

3. 类型:

以营利为目的的结社——属于民法调整的范围 公司

非营利性质的结社——宪法调整的范围

尤其是: 政治目的的结社 宗教目的的结社

4. 管理体制: 政治选举 提出政见

许可制 登录制 追惩制

人人具有非经公共团体许可自由结社的权利

主要是政府

中国的双重许可制 (大概是登记+许可?) 业经主管单位同意+民政部门登记 (政治/宗教目的才需要)

5. 结社的限制

禁止

以犯罪为目的的结社

以反抗、推翻现有宪法制度的结社

限制

公务员结社 法官结社 军人结社

事务类 司法中立 军事政变 军人参政

